

1500174-35.2022.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... o acusado em local de conhecido ponto de tráfico após denúncia anônima, terem visualizado atos de comércio e terem encontrado a droga em sacola por ele portada. O policial civil Thiago disse que recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo estaria fazendo tráfico (PAULO) e outro estaria dando apoio (ALEXANDRO), recebendo os usuários-clientes, em via pública a Biqueira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá (SP) - cep 11730-000

1500174-35.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500174-35.2022.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO VITOR SANTOS DA SILVA e outro

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra PAULO VITOR SANTOS DA SILVA e ALEXANDRO DA SILVA MACHADO imputando-lhes a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Sustenta a denúncia que, no dia 24 de março de 2022, por volta das 18h20, na Rua Adrião Dias, nº 1464, Balneário Jussara, nesta cidade e comarca de Mongaguá, PAULO e ALEXANDRO, previamente ajustados e agindo em concurso de agentes, traziam consigo, para fins de tráfico, 133 porções de cocaína, com peso bruto de 92g, 634 pedras de crack, com peso bruto de 176g e 95 porções de maconha, com peso bruto de 142g, conforme auto de exibição/apreensão de fls. 55/56 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 57/58.

Narra que, a equipe da Polícia Civil recebeu informações anônimas de que dois indivíduos, com determinadas características, realizavam a traficância no local dos fatos, conhecido como "Biqueira da Nove". Chegando ao local dos fatos, os policiais, em breve campanha, encontraram dois indivíduos, com as mesmas características informadas, quando foi possível visualizar o "olheiro" e o outro elemento, recebendo dinheiro e entregando drogas aos usuários, sendo certo que os entorpecentes eram retirados de uma sacola plástica. Diante destes fatos, os agentes da lei decidiram pela abordagem. O vendedor das drogas foi identificado como PAULO. Com ele, os agentes encontraram a quantia de R\$ 13,00 em moedas, além de porções de maconha. PAULO ainda trazia consigo uma sacola plástica, em cujo interior foram encontradas as demais drogas anteriormente descritas. Ainda, os agentes da Polícia Judiciária lograram êxito da captura do indivíduo que realizava

a função de “olheiro”, identificado como ALEXANDRO. As circunstâncias da abordagem, as atitudes dos denunciados, o local dos fatos e a apreensão de certa quantia de procedência não esclarecida dão conta que os inculcados praticavam a mercancia ilícita de entorpecentes.

As prisões em flagrante foram convertidas em preventiva (fls. 106/108).

Laudo pericial acostado a fls. 138/140.

A denúncia foi recebida (fls. 106/108) e os réus foram citados (fls. 106/108), o corréu PAULO apresentou resposta à acusação a fls. 105.

Em audiência foram colhidas as declarações do ofendido e os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado PAULO confessa a prática delitiva, mas diz que era o primeiro dia em que se envolveu com o tráfico em razão da necessidade financeira, e que não conhece ALEXANDRO, que sequer estava no local dos fatos; e ALEXANDRO nega a autoria delitiva, dizendo que estava chegando no trabalho, no Bar Mandraque, à Rua Adriano Dias, nas proximidades do local.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da pretensão acusatória, defendendo a suficiência probatória, inclusive da participação de ALEXANDRO na conduta de comércio praticada por PAULO, bem assim a fixação da pena-base no mínimo, a consideração da agravante da reincidência a ALEXANDRO e da atenuante da confissão a PAULO, bem como o afastamento da causa de diminuição de pena diante do local em que realizado o comércio ilegal e da confissão de que recebeu, no suposto primeiro dia de PAULO, cerca de R\$ 8.000,00 em drogas para o comércio, além da reincidência de ALEXANDRO. A defesa técnica de PAULO fez remissão a memorial escrito (fls. 188/191), em que pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória e incongruência do depoimento dos policiais, subsidiariamente defendendo a aplicação da atenuante da confissão e da figura privilegiada. E a defesa de ALEXANDRO, pela absolvição, porque com ele não havia droga nenhum ou valores, estando apenas na frente do bar em que trabalhava, inclusive conforme documentação acostada, e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do artigo 37 da Lei 11.343/06.

Folha de antecedentes e certidão de distribuição estão a fls. 72, 75/84 e 92/101 e fls. 73/74 e 102/104.

Fundamentação

Existência e Autoria

A existência e a autoria delitivas restaram parcialmente demonstradas pelas provas pericial e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, em massa líquida correspondente a 14,7g (cocaína), 84,9g (“crack”) e 104,9g (maconha).

A própria variedade e quantidade de droga apreendida, bem superior ao que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, corrobora a versão acusatória no sentido de que seu destino não era o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros), de até 16 pedras de crack (cerca de 5,2g) e de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercilio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades,

gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

Quanto ao crack, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o padrão médio de uso no Brasil de 13,42 porções por dia apurado por pesquisa da FIOCRUZ, idealizada em conjunto com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Pesquisa Nacional sobre o Uso do Crack, 2014); com o uso de mais de 10 pedras por episódio relatado por 47% de 67 usuários de crack atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010); com o relato de uso de 10 ou mais pedras por 69,5% de 67 usuários de crack atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial de Igrejinha, Taquara e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul (Rogério Lessa Horta et al, Perfil dos usuários de crack que buscam atendimento em Centros de Atenção Psicossocial. Cad. Saúde Pública, v. 27, n. 11, p. 2263-2270, 2011); e com a média de 73,2 pedras de crack por semana encontrada em pesquisa com 72 pacientes do Centro de Atenção Psicossocial de Serra, no Espírito Santo (Janine Andrade Moscon, Avaliação dos padrões de consumo de crack, cognição global e de funções executivas em usuários de ambulatório especializado de alta demanda, Mestrado, UFES, 2013).

Quanto à cocaína, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991 e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga – ainda assim, no caso, a quantidade é realmente expressiva e desborda do consumo pessoal.

E a autoria delitiva quanto a PAULO também restou comprovada pelos elementos probatórios colhidos, somando-se à confissão judicial do acusado (artigo 197 do Código de Processo Penal).

Com efeito, os policiais atestaram ter abordado o acusado em local de conhecido ponto de tráfico após denúncia anônima, terem visualizado atos de comércio e terem encontrado a droga em sacola por ele portada.

O policial civil Thiago disse que recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo estaria fazendo tráfico (PAULO) e outro estaria dando apoio (ALEXANDRO), recebendo os usuários-clientes, em via pública a Biqueira da Nove, mencionado características de cor da pele, estatura, camiseta de futebol. Ficaram em campanha a cerca de 50-100m do local com movimentação de pessoas e identificaram os acusados em movimentação típica do comércio de entorpecentes. O segundo indivíduo, “em campanha”, além de receber os clientes fazia a observação e avisava diante da aproximação de policiais ou pessoas estranhas. Aproximaram-se em viatura descaracterizada e surpreenderam PAULO com uma sacola com a droga e com dinheiro no bolso e, depois, seu colega abordou ALEXANDRO. Na Delegacia, PAULO confessou a prática, mas disse que estava há pouco tempo – tanto assim que não tinham o visto antes. O local, Biqueira da Nove, é ponto contínuo de tráfico de droga e, por ficar em via pública, na frente de comércio, a abordagem policial é facilitada e recebem informações de moradores ou transeuntes. Avistou ALEXANDRO receber usuários e guiá-los até PAULO e gritar quando via carro desconhecido ou de guardas municipais ou da

polícia militar. Thiago prendeu PAULO, que estava com uma sacola com droga e nos seus bolsos havia um pino e pouca quantidade de dinheiro. Os acusados estavam na frente de um boteco, na porta. A despeito da distância, visualizou a negociação por cerca de 20 ou 30 minutos, durante os quais PAULO, por vezes, entrava e saía do boteco. Visualizou mais de cinco trocas de objetos da sacola contendo a droga e o recebimento de dinheiro. Não se recorda o que foi encontrado com ALEXANDRO, mas acredita que nenhuma droga. Ele exercia a função de informante, de “campana”. No local costumam atuar 3 ou 4 “campanas”.

O policial Hélio disse que a região é local conhecido de tráfico ininterrupto de drogas e recebe denúncias por vários canais. Naquele dia, fizeram campana próxima ao número 1.450, com viatura descaracterizada, e receberam denúncia de um indivíduo branco no tráfico e outro em serviço de “campana”. Visualizaram o fluxo de usuários de droga fazendo a mercancia e resolveram fazer a abordagem. Em revista pessoal, encontraram com PAULO algumas porções de maconha e, na sacola, uma quantidade um pouco maior de droga. ALEXANDRO estava do outro lado da rua, direcionando os usuários de droga para PAULO, para fazerem a compra. O depoente fez a abordagem de ALEXANDRO. Fizeram campana a cerca de 100m do ponto de venda. Perguntado sobre a grande movimentação de pessoas na região, confirmou que teve a plena visualização dos atos, até porque tinham informação prévia das características da pessoa traficando no local. Não sabe dizer quantos atos de comércio foram visualizados durante a campana, mas informalmente PAULO confirmou que tinha passado quase o dia todo fazendo a mercancia. Efetuiu a abordagem de ALEXANDRO, segundo se recorda, e com ele não encontrou nada de ilícito. ALEXANDRO dava apoio a PAULO, permanecendo do outro lado da rua, avisando a aproximação de carros suspeitos ou de viaturas. Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação quanto à responsabilidade penal de PAULO e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Contudo, o mesmo não se pode dizer quanto a ALEXANDRO, cuja participação no delito não foi suficientemente demonstrada.

Negados os fatos pelos acusados, o único elemento probatório no sentido da versão acusatória que veio aos autos foi o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Não há qualquer outra prova que possa ser confrontada com o depoimento e a ele se somar. Nada mais há a ligar os acusados à conduta criminosa. Ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Não se está a duvidar da veracidade dos depoimentos prestados a este juízo por quem cumpre nobre e corajosa função no sistema de segurança pública em uma sociedade brasileira tão desigual e fragmentada, mas o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos.

Mutatis mutandis é o que levou o Superior Tribunal de Justiça a exigir mais do que a palavra dos agentes policiais para resultar válida a autorização de ingresso no domicílio, verbis: “7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a

diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado." (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Tal entendimento também foi sufragado pela Quinta Turma: HC 616.584/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021.

Crer que a palavra dos policiais envolvidos na formação da opinião delicti seja suficiente para a condenação desde que não infirmados ou refutados pela defesa é impor indevida inversão do ônus probatório, que é da acusação, e violar, por via transversa, o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal (cf. Aury Lopes Jr., Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529-530). Afinal, em última análise, o destino do acusado já estaria selado tão somente pela atuação do agente policial.

No caso, a situação se agrava diante do quanto atestado pelas testemunhas. Ora, se se tratava de ponto conhecido de venda de drogas e se os policiais organizaram previamente a realização de campanha, era de todo possível a produção de outros elementos probatórios, como fotografias ou filmagens da ação criminosa, senão da própria abordagem.

Enfim, o titular da ação penal não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, restando dúvida quanto à responsabilidade penal do acusado ALEXANDRO. Assim, não afastada a presunção de inocência a todos assegurada pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, corolário de um Estado Democrático de Direito, impõe-se a absolvição.

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

A acusação não logrou demonstrar que o agente seja reincidente, tenha maus antecedentes, se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão pela qual aplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Ao contrário, a folha de antecedentes indica a primariedade do acusado, e o único elemento trazido é o indício que se extrai da quantidade de droga apreendida e confiada ao acusado para a comercialização no ponto de vendas.

Contudo, a apreensão de quantidade não módica de droga em poder do acusado não é indício suficiente para, isoladamente, permitir se conclua que o acusado se dedica às atividades criminosas, pois daí não se extrai conclusão segura (STF, HC 138138, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016), a menos que se trate de quantidade realmente exorbitante ou que haja outros indícios, o que não é o caso.

Note-se que a ausência de emprego formal ou de mesmo de comprovada ocupação lícita não autoriza concluir, automaticamente, se dedique o acusado à atividade criminosa, em verdadeira inversão do ônus da prova, incompatível com a presunção de inocência, menos ainda diante da importância, senão preponderância, da economia e do emprego informais, marcas da desigualdade social que a sociedade e o Estado brasileiro ainda não lograram reduzir (v. artigo 3º da Constituição Federal).

Ilicitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que

excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal. À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado não ostenta Maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fermín Ramírez vs. Guatemala, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga são importantes e não autorizam um juízo favorável ao acusado, pois superiores ao suprimento mensal de um usuário de droga, conforme os parâmetros já indicados e considerada a soma da massa líquida de todas

as drogas, mas não são expressivas a ponto de justificar a elevação da pena-base. Por tudo isto, considerado favorável a conduta social e neutras as demais circunstâncias. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o intervalo de pena em abstrato a cada circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar, em tese, o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 8 anos de reclusão.

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), é de rigor a atenuação da pena em razão da confissão (artigo 65, inciso III, 'd', do Código Penal) e em razão da menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Por conseguinte, atenuo a pena em 1/3 sobre o intervalo de pena em abstrato, que é reduzida para o mínimo de 5 anos.

Por fim, na terceira etapa, reduzo a pena de 2/3, no patamar máximo do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, do qual não se extrai critério seguro para gradação, em ofensa ao princípio da legalidade (artigo 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal), evitando-se, ainda, inadmissível bis in idem na dupla valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal combinado com o artigo 42 da Lei 11.343/06) na primeira e na terceira etapas.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, correspondendo a pena-base a 600 dias-multa e a pena intermediária a 500 dias-multa, fixo a pena de multa final em 166 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 43 da Lei 11.343/06, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Diante da condenação a pena igual ou inferior a 4 anos, da primariedade do réu e das circunstâncias judiciais que não se mostram desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'c', do Código Penal (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal).

É inaplicável ao tráfico privilegiado a previsão constante do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, porque não se trata de crime equiparado a hediondo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016), ao que se curvou o Superior Tribunal de Justiça revendo a tese fixada em recurso repetitivo e cancelando a sua Súmula 512, para assentar que "o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo" (Pet 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Substituição e sursis

Diante das circunstâncias judiciais em torno do crime e do acusado (artigos 44, inciso III, e 59, inciso IV, do Código Penal) e do preenchimento dos requisitos objetivos dos incisos I e II do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade superior a 1 ano por duas restritivas de direitos, na forma do artigo 44, parágrafo 2º, do Código Penal, lembrando que o Senado Federal suspendeu a execução, nesta parte, da vedação disposta no artigo 33, parágrafo 4º,

da Lei 11.343/06 após decisão do Supremo Tribunal Federal.

A fim de atender às finalidades preventiva e retributiva da sanção penal e permitir, na medida do possível, a restauração dos efeitos do delito na comunidade, determino a substituição por prestação de serviços à comunidade ou a entidades pública (artigo 46 do Código Penal), a ser especificada e adaptada quando da execução (artigos 148 e 149 da Lei de Execução Penal), e pela interdição temporária de direitos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, ficando o acusado proibido de frequentar as imediações do local do fato, em que mantido ponto de comércio de entorpecentes, pelo tempo da pena privativa de liberdade.

Indicada a substituição da pena por restritiva de direitos (art. 44 do CP), é incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP), até porque aquela se mostra mais propícia à rápida ressocialização do acusado.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar PAULO VITOR SANTOS DA SILVA à pena de reclusão de 1 anos e 8 meses, em regime inicial aberto, e a 166 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a causa de diminuição do parágrafo 4º do mesmo dispositivo, substituída pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e de proibição de frequentar as imediações do local do fato; e, no mais, julgo improcedente a pretensão acusatória e absolvo o réu ALEXANDRO DA SILVA MACHADO da imputação inicial, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Prisão preventiva

Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, aprecio e revogo a prisão preventiva, porque incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade." (HC 193996 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020). No mesmo sentido: HC 136397, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016.

Quanto a PAULO, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e, sobretudo, de assegurar a aplicação da lei penal, é necessário, adequado e suficiente a concessão da liberdade provisória mediante a determinação de a) comparecimento perante a autoridade policial ou judicial todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento; b) proibição de se ausentar da Comarca por mais de 8 dias sem prévia autorização do Juízo; c) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades. Tudo na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, expeça-se, com urgência, os alvarás de soltura clausulados.

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu PAULO ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03), mas deixo de condenar o Ministério Público, vencido, ante a isenção do artigo 6º da Lei Estadual 11.608/03. A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, se o caso, e a guia de recolhimento definitiva, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010; comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal).

Ainda com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Também após o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; expeça-se a certidão de honorários ao

advogado dativo, se o caso; expeça-se a competente certidão para execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).

Comunicado o ajuizamento da execução da multa (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou verificada a prescrição da pretensão executória (evento 22), arquivem-se os autos com a movimentação 61619 no SAJ.

Int.

Mongaguá, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA